



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Conselheiro-Substituto Márcio Martins de Camargo

Tribunal Pleno – **SEÇÃO MUNICIPAL**

Sessão: **21/08/2024**

Exame Prévio de Edital – **Julgamento**

M-003: TC-013545.989.24-6

Interessada: Prefeitura de Artur Nogueira

Responsável: Lucas Sai Rissato (Prefeito); Aldo José Todero Junior (Secretário de Administração); Angela Pulz Delgado (Secretária da Saúde)

Representante: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.

Assunto: Representação formulada em face do edital do Pregão Eletrônico nº 014/2024, instaurado pela Prefeitura de Artur Nogueira, objetivando a prestação de serviços de gerenciamento, administração e implementação de créditos para vale-alimentação

Valor estimado: R\$ 996.000,00

Advogados (cadastrados no e-TCESP): Clayton Machado Valério da Silva – OAB/SP 212.125 e outros (Representada); Rafael Prudente Carvalho Silva – OAB/SP 288.403 (Representante).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO. CRITÉRIOS DE DESEMPATE. MICROEMPRESAS E SOCIEDADES DE PEQUENO PORTE. PRAZO DE PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CORREÇÕES DETERMINADAS.

1 – Na ocorrência de empate das propostas dos licitantes, a Administração deverá observar o direito de preferência assegurado às microempresas e sociedades de pequeno porte e as regras estipuladas no art. 60 da Lei nº 14.133/21.

2 – Deverá ser reavaliado o prazo de pagamento previsto, a fim de compatibilizá-lo ao usualmente adotado pelas empresas deste respectivo segmento de mercado.

Relatório

Trata-se de representação formulada pela Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. em face do edital Pregão Eletrônico nº 014/2024, instaurado pela Prefeitura de Artur Nogueira, objetivando a prestação de serviços de gerenciamento, administração e implementação de créditos para vale-alimentação, nos termos dispostos no ato convocatório.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

De forma breve, reclamou que houve inovação nos critérios de desempate previstos no edital e que não seria respeitado o direito de preferência das microempresas e sociedades de pequeno porte neste quesito.

Também se queixou da regra de pagamento (de forma pós-paga), destacando que o prazo de trinta dias após a emissão da nota fiscal seria impraticável neste respectivo segmento de mercado.

Em face da necessidade de uma análise mais apurada, a matéria foi recebida pelo Tribunal Pleno nesta via processual (evento 23).

Na sequência, a Origem encartou aos autos a documentação devida e suas justificativas – alegando, em síntese, que o edital observou a legislação vigente e a jurisprudência deste Tribunal (evento 59).

Os Órgãos da Casa (Assessoria e Chefia da ATJ, MPC e SDG) convergiram, na direção da procedência, em parte, do pedido (eventos 64.1, 64.2, 69 e 79).

É, na essência, o relatório.

fnp



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Voto

TC-013545.989.24-6

Se, de um lado, com o advento da Lei nº 14.442/22, houve a proibição da oferta de qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos em certames da espécie (art. 3º, I), de outro a perspectiva factual de empate entre as licitantes diante desta vedação não autoriza, per se, a inovação de critérios de resolução da demanda não previstos taxativamente no art. 60 da Lei nº 14.133/21, na ordem ali transcrita¹.

No caso em exame, evidente o conflito, já que os critérios baseados no maior número de pontos credenciados ou de municípios, de transações com o comércio local e na menor taxa administrativa², além de revelar antecipação indevida da demonstração da rede e favorecimento injustificado às empresas que já detêm credenciados os estabelecimentos, não se amoldam às hipóteses contidas naquele dispositivo legal, comportando retificação.

Por simetria, necessário pontuar que, antes mesmo da aplicação das regras de desempate aplicáveis ao segmento em geral, deverá ser

¹ Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

I - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

² Item 9.20.1 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Item 3.7 do Termo de Referência, conforme anexo I do edital, nesta ordem:

9.20.1.1 - maior número de pontos credenciados no município;

9.20.1.2 - maior número de transações realizadas no comércio local;

9.20.1.3 - menor taxa administrativa cobrada aos comerciantes;

9.20.1.4 - maior número de municípios com pontos credenciados na região num raio de 40 km.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

assegurado o direito de preferência às microempresas e sociedades de pequeno porte, à luz do que preceitua os artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06.

Em outras palavras, decretado o empate, seja ficto¹ ou real, necessário observar esta cronologia:

- a) se entre uma proponente enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) e outra licitante não incluída neste regime, caberá a ME ou EPP a preferência na contratação;
- b) se houver mais de uma ME ou EPP, a disputa será resolvida por sorteio somente entre elas; e
- c) se entre licitantes não beneficiárias da Lei nº 123/06, a solução será a aplicação do art. 60 da Lei nº 14.133/21 - com a cautela da observância estrita aos parâmetros ali estabelecidos e com a ressalva de que, neste caso, não houve previsão de sorteio na norma citada.

Oportuno acrescentar, a estas diretrizes, a inviabilidade do emprego em sua plenitude do inciso II, art. 60 da nova Lei de Licitações, ao menos neste momento – já que o cadastro unificado no Portal Nacional de Contratações Públicas, catalogado como instrumento auxiliar das licitações, ainda pende de regulamentação².

Esta tem sido a linha jurisprudencial da Casa, conforme excerto do r. voto proferido pela Conselheira Cristiana de Castro Moraes nos autos do TC-014377.989.23, com a propriedade que lhe é peculiar, como segue (acolhido pelo Tribunal Pleno, sessão de 16/8/2023):

“Conforme salientado em citado julgamento, em sendo inviável se valer, para essa finalidade, de registros cadastrais do Portal Nacional de Contratações Públicas, dado que o sistema unificado previsto no

¹ Nos termos do art. 44, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 123/06.

² Art. 87. “Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública deverão utilizar o sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), para efeito de cadastro unificado de licitantes, na forma disposta em regulamento.”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

artigo 87 da Nova Lei de Licitações e Contratos ainda depende de regulamentação, a aferição de performance, para fins de desigualar proponentes, não deve se distanciar do disposto no §3º do artigo 88 do mesmo diploma, de sorte que deve buscar 'avaliar a atuação do contratado, no desenrolar das avenças, com base em indicadores objetivos e anotações de eventuais penalidades aplicadas.'

[..]

Cabe ressaltar, contudo, que, constatada a eventual inviabilidade, segundo crivo do órgão promotor do certame, para implementação na prática de tal fator de discrimen, considera-se lícito que se abstenha de empregá-lo, sem prejuízo de obedecer, então, os demais critérios estabelecidos no artigo 60 da Nova Lei de Licitações e Contratos, a exemplo do que restou decidido no processo n.º TC-012996.989.23-2 (Sessão Plenária de 19/07/2023, sob minha relatoria).

[...]

Deste modo, aplicando as diretrizes expostas ao certame em apreço, orienta-se a Municipalidade para que modifique o ato convocatório, a fim de que, na hipótese de haver uma única licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte ofertante de taxa de administração igual a zero, dê-lhe preferência para contratação, satisfeitos os demais requisitos editalícios, ainda que ocorram ao torneio outras interessadas de maior porte com proposta idêntica.

Caso haja mais de uma empresa com oferta igual a zero beneficiária da Lei Complementar Federal n.º 123/2006, proceda ao sorteio apenas entre elas.

Somente na hipótese de o empate envolver unicamente participantes não qualificadas como microempresas e empresas de pequeno porte, deve a Prefeitura seguir para os citados parâmetros do artigo 60 e do respectivo § 1º da Lei Federal n.º 14.133/2021.”.

De outro norte, não prospera a crítica dirigida ao momento para o pagamento (pós-pago), diante da evolução jurisprudencial desta Corte sobre a tema, na direção da observância dos estágios da despesa pública (empenho, liquidação e pagamento), estampados nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

Confira-se, a respeito, a ementa contida nos autos do TC-8227.989.23 e outros, de relatoria do Titular deste Gabinete (Pleno de 10/5/2023, rel. Cons. Robson Marinho):

“EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CHAMAMENTO PÚBLICO. INTERMEDIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES COM VALE-REFEIÇÃO. CREDENCIAMENTO. REPASSE DOS CRÉDITOS RELATIVOS AOS CARTÕES DOS BENEFICIÁRIOS. ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO MÁXIMO DE 0,90. REDE MÍNIMA DE ESTABELECIMENTOS POR MUNICÍPIO. PRAZO PARA CADASTRAMENTO INICIAL DE 50% DA REDE PREVISTA.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

ARRANJO DE PAGAMENTO. AUDIÊNCIA PÚBLICA. PARCIALMENTE PROCEDENTE. Considerando que em contratos para fornecimento de vales refeição e alimentação a despesa pública corresponde à soma da taxa de administração superior a zero com o repasse dos numerários relativos aos créditos dos cartões dos beneficiários, este repasse é pagamento de despesa pública e deve respeitar os estágios dos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64.”.

Aliás, ainda com base neste julgado e à míngua de argumentos robustos ofertados pela Representada, a Municipalidade deverá reavaliar o prazo de pagamento (trinta dias após a emissão da nota fiscal), a fim de compatibilizá-lo ao usualmente adotado pelas empresas deste respectivo segmento ao remunerar os estabelecimentos comerciais, conforme pontuaram Assessoria da ATJ, MPC e SDG.

Sobre o assunto, rememoro trecho contido na deliberação citada no parágrafo anterior:

“De qualquer modo, considerando que o prazo de 30 (trinta) dias do recebimento do objeto, fixado na cláusula impugnada, é o limite máximo do art. 40, XIV, ‘a’, da Lei 8.666/93 – ‘prazo de pagamento não superior a trinta dias’ -, e que a Universidade de São Paulo não justifica a razão de usar todos esses 30 (trinta) dias posteriores ao recebimento do objeto e a viabilidade de mantê-lo inclusive para o repasse dos créditos referentes aos cartões dos beneficiários, as queixas das representantes procedem em parte.

Por tudo isto é que entendo ser parcialmente procedente a insurgência contra o item 10.1 da minuta do contrato, razão pela qual a Universidade de São Paulo deve rever esses 30 (trinta) dias de prazo para pagamento, contados do recebimento do objeto, a fim de ajustá-lo ao contexto dos prazos envolvidos para o pagamento dos estabelecimentos comerciais pelas futuras empresas credenciadas.”.

Diante do exposto, voto pela **procedência parcial** da representação, devendo a Prefeitura de Artur Nogueira observar a ordem de preferência destinada às microempresas e sociedades de pequeno porte e os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, além de conformar o prazo de pagamento ao usualmente adotado pelas empresas deste respectivo segmento de mercado, nos termos aqui consignados.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Ao republicar o edital com as devidas alterações, a Administração deverá observar a reabertura do prazo legal, em obediência ao que preceitua o artigo 55, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

Acolhido este entendimento pelo Plenário, intime-se a Representada, na forma regimental.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

É como voto.